



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

市场混淆行为

内容提要

- 概述
- 擅自使用商品类标识
- 擅自使用商号类标识
- 擅自使用互联网类的标识及其他

一、市场混淆行为的概念

- 市场混淆行为（**Passing off**）是指经营者采用假冒、仿冒等欺骗性手段从事市场交易，使自己的商品或服务与特定竞争对手的商品或服务**相混同**，造成或足以造成购买者**误认**误购的不正当竞争行为。
- **对象——商业标志**
- 商业活动中具有识别性或区分性的标志，能够起到区别商业活动中的商品（服务）来源、经营者或者经营活动的作用。

《反不正当竞争法》 第七条

- 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与**他人存在特定联系**：
 - 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识（**商品类**）；
 - 擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；（**商号类**）
 - 擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页、**新媒体账号名称、应用程序名称或图标**等；（**互联网类**）
 - 其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。（**兜底**）

（一）商标法和反法的关系

- 1.在自己经营的商品中擅自使用他人**注册商标、未注册的驰名商标**，应当适用《商标法》处理。
- 2.将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，或者将他人商品名称、企业名称（包括简称、字号等）、注册商标、未注册的驰名商标等**设置为搜索关键词**，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，属于反法规制的混淆行为。
- 3.保护在本质上具有一致性
- 小肥羊曾被同时认定为未注册的驰名商标和知名商品名称

商标法与反法的分工

- 商标法与反法的交集主要在于未注册商标的保护
- **1.商标法主要是在授权和确权过程中提供保护**
- **防止抢注**
 - 《商标法》第**13**条第**2**款，制止抢注他人未注册的驰名商标
 - 《商标法》第**15**条，制止代理人抢注
 - 《商标法》第**32**条，禁止恶意抢注在先有一定影响力的商标
- **2.反法补充性保护**
 - 制止使用未注册商标造成混淆的行为

（二）“有一定影响”的商业标识

标识必须“有一定影响”



1. 标识在“相关公众”中**有一定的知名度**；
2. **足够显著**能使“相关公众”能够识别商品或其来源。

（在知名度的基础上还要求具有**美誉度**，不鼓励具有负面、消极影响的标识以哗众取宠的方式被周知。）

考量因素：使用持续的时间、区域、销售量或者广告宣传

“有一定影响”的判定

- **1.在中国境内的影响**
- **2.在相关公众中的影响**
 - 相关公众：与该商品有特定交易关系的群体
- **3.特定地域范围内的知名度**
 - 注意与驰名商标的区别：全国知名
 - 知名度的地域范围=保护范围？
 - 依据反法的目标予以调整
 - 1) 恶意模仿，则保护范围不限知名的地域范围
 - 2) 不同地域+善意使用=不侵权
 - 3) 不同地域——地域交叉，附着一定的区别标识

不能被认定为“有一定影响的商品标识”

1. 商品的通用名称、图形、符号
2. 仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称；
3. 仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及商品具有实际性价值的形状；
4. 其他缺乏显著性的商品名称、包装、装潢
5. 2、4情形中经过使用产生显著特征的，可以认定为特有的名称、包装或者装潢。

司法解释第五条



Dior
迪奥



上海交
HANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

学院

ROGUAN LAW SCHOOL

山东鲁锦实业诉鄄城县鲁锦等公司

- 鲁锦公司认为鄄城鲁锦等公司大量生产、销售标有“鲁锦”字样的鲁锦产品，侵犯其“鲁锦”注册商标专用权。鄄城鲁锦公司企业名称中含有原告的“鲁锦”注册商标字样，误导消费者，构成不正当竞争。“鲁锦”不是通用名称。请求判令被告承担侵犯商标专用权和不正当竞争的法律责任。
- （最高人民法院第46号指导案例）

法院认为：

- 山东省及济宁、菏泽等地方史志资料在谈及历史、地方特产或传统工艺时，对“鲁锦”也多有记载，均认为“鲁锦”是流行在鲁西南地区广大农村的一种以棉纱为主要原料的传统纺织产品，是山东的主要民间美术品种之一。
- 相关工具书及出版物也对“鲁锦”多有介绍，均认为“鲁锦”是山东民间手工织花棉布，以棉花为主要原料，手工织线、染色、织造，俗称“土布”或“手织布”，因此布色彩斑斓，似锦似绣，故称为“鲁锦”。

法院认为：

- 判断具有地域性特点的商品通用名称，应当注意从以下方面综合分析：
 - 该名称在某一地区或领域约定俗成，长期普遍使用并为相关公众认可；
 - 该名称所指代的商品生产工艺经某一地区或领域群众长期共同劳动实践而形成；
 - 该名称所指代的商品生产原料在某一地区或领域普遍生产。

避风塘公司诉德荣唐公司

- 创始于**1998**年的上海避风塘美食有限公司，经过多年发展，已成为在上海拥有近**20**家分店的大型餐饮连锁机构。经营中，该公司一直使用“避风塘”及其相关标识进行宣传，并成功注册了“避风塘”图文**商标**、**BI FENG TANG**拼音商标。
- 认为被告在其招牌、匾额、店堂餐桌以及广告上擅自使用“避风塘”字样，是不正当竞争。
- （2002）沪一中民五（知）初字第137号

最高院的观点

- “避风塘”一名源于香港，最初是指香港渔民躲避台风的港湾。后来，渔民在港湾附近打捞鱼虾并以简单的烹饪方法（油盐水、艇仔粥）进行加工并销售给游客，这种料理因保留了鱼虾等食材的原味和鲜美而广受欢迎，“避风塘”一词遂由地理名词逐渐发展成为一种特别的风味料理或者烹饪方法的通用名称。
- 经过申诉人在其企业名称中的长期使用和在商业标识意义上的广泛宣传，在上海地区的餐饮服务业中，“避风塘”一词同时具有识别经营者身份的作用，能够表明特定餐饮服务的来源。

三、是否构成混淆的判断

直接混淆：

引人误认为是他人商品。

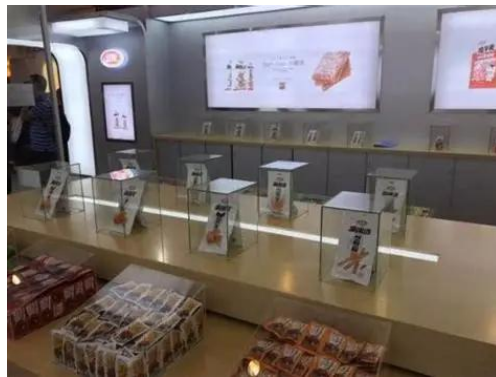
间接混淆：

引人误认为与他人存在特定联系，此种特定联系要与经营者信誉、商品声誉有关，如具有授权生产、研发成果应用、产品监制、提供保障等方面的特定联系。

联想混淆：

今日头条与今日油条

修订后条款不对联想混淆进行禁止，相关公众虽会对两种产品产生联想，但联想对行为人产品的交易机会不会造成显著影响。



如此店铺与苹果公司展示方式很像，但是卖食品，属于联想混淆，不会对交易机会产生显著影响

判断标准

消费者，经营人员

- 以相关公众的普遍认知为判断标准，考虑相关公众在该类商品选择上施加的一般注意力。
比如买水，很可能注意力比较低，不太在意；但是买贵的东西，比如电脑、车等等，一般注意力较高，产生误认的可能性相对较低
- 造成误认包括两种情况：
 - 已经引起误认、客观上已经发生了购买者对有关商品的认识出现混同的情形；
 - 可能引起误认的情形。

五、如何理解“擅自使用”？

- 从客观的行为表现判断行为人是否具有不正当竞争的主观恶意。
 - 没有获得授权而进行使用；
 - 故意造成混淆的使用。

澳洲一出名红酒厂：Penfold, 中文名 奔富；

另一红酒厂：奔富尼澳，但是图标和其相似，并且图标奔富大，尼澳二字小

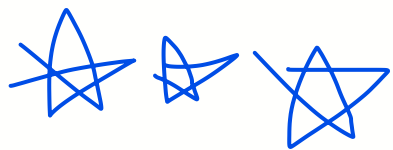


内容提要

- 概述
- 擅自使用商品类标识
- 擅自使用商号类标识
- 擅自使用互联网类的标识及其他

(一) 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；





特殊问题一

- 包装是为识别以及方便携带、储存而使用在商品上的辅助物和容器。

更强识别性

- 装潢是为识别与美化商品而在商品或者包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。



广药与加多宝之争

初期



官司输了，改为金色



最高院判决，双方都有贡献，故可以用红色包装

背景

- 1997年时，广药集团持有王老吉商标，加多宝（隶属香港鸿道集团）从广药购得10年商标使用权，用于生产红罐王老吉，广药则继续生产绿色利乐包装的王老吉。
- 在一般的市场混同案件中，知名商品的认定不会存在区别具体商品的问题，只要界定的知名商品指代能够足以与其他同类商品相区别，如“费列罗巧克力”等，便可以支持案件审理。该案的原被告双方是此前具有商标许可使用关系的许可人与被许可人，同时存在原被告各自生产的王老吉凉茶商品。



广东高院判决认为

- 商标与包装装潢已经融为一体，此时不应将商标与包装装潢的其他组成部分割裂开来。
- 本案红罐凉茶包装装潢上，“王老吉”字样已经与本案红罐凉茶包装装潢的其他组成部分紧密地结合在一起，已经成为该包装装潢的一个重要组成部分。
- 本案红罐凉茶包装装潢已经不能脱离王老吉商标而单独存在；本案知名商品特有包装装潢应认定为包括“王老吉”字样的红罐包装装潢整体。

最高人民法院认为：

- 广药集团与加多宝公司对涉案“红罐王老吉凉茶”包装装潢权益的形成均作出了重要贡献，双方可在不损害他人合法利益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益。

现在，两家企业经营效果都大不如前；商业标识如果同时被两家共享，两家对于维护商标商誉的意愿都不足，因此商标价值下降

特殊问题二

- 营业场所装饰、员工的服装是否可以作为包装、装潢？

由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象，可以认定为装潢。



内容提要

- 概述
- 擅自使用商品类标识
- 擅自使用商号类标识
- 擅自使用互联网类的标识及其他

- “（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；”

一、企业名称的构成

- 依照《企业名称登记管理规定》（1991），“企业名称”是由行政区划、字号、行业或经营特点、组织形式四部分组成的。

— 公司全称=地区+字号+行业+组织形式

• 北京小桔科技有限公司 滴滴公司

《企业名称登记管理条例（征求意见稿）》（2018）

主要问题

- 国内问题

- 原因：企业注册没有全国登记
- 现象：同一名称被不同企业在不同区域内适用
- 结果：
 - 不交叉就没问题
 - 交叉的话，共用

- 国际问题

- 主要是翻译产生的问题

企业名称的保护范围

注册区域

影响力范围

- 1.企业名称专用权的范围与禁止权范围
- 萧某VS北京信远斋饮料有限公司

北京西城区福绥
信远斋蜜果店



更宽
实际有影响
力的范围

原告虽然登记注册了北京市西城区福绥境信远斋蜜果店，但从2000年至今该店一直未从事经营活动，没有生产、销售过任何产品(或从事过营利性服务)，不存在现实的市场利益及交易对象，故原告并非实际的经营者。

企业名称与商标保护的冲突

1, 保护经营者对于商标的贡献
2, 保护消费者的权利, 因为标识已经和
产品服务深度绑定, 因此标识可以帮助消
费者认牌购物, 降低交易成本

- 一般而言, 商标权优于企业名称权
- 原因:
 - 1、商标用于区分商品和服务来源
 - 2、企业名称用于标识企业身份信息
- 福成养牛集团诉哈尔滨福成餐饮公司 (昆明福成)
- 例外: 抢注他人有一定影响力的企业名称 (在先权利)
- 判断因素:
 - 应当使用全称, 否则就疑似是在将企业名当商标用
 - 1、是否正常使用企业名称 (突出使用?)
 - 2、使用是否会造成混淆 (相同或类似)



国外企业名称问题

- 国外著名企业尚未登记的企业名称保护问题：主要的依据是知名度
 - 谷歌中国诉谷歌北京案：支持
 - 万多吉国际诉万多吉商贸案：不予支持（知名度不够）
- 外国企业名称的中文翻译问题
 - 凯摩高（**Camoga**）诉盐城凯摩高案：被告使用凯摩高和**Camoga**的名称
 - 判决：被告不得使用**Camoga**；但是，原告无法证明“凯摩高”和**Camoga**质检存在唯一、特定的联系和指向
 - 依然是知名度的问题

二、简称

- 公众已经对于某简称熟知，且存在唯一指代。
- 正面案例
 - 清华大学与“清华”（清华诉团结出版社）
 - 济南钢铁集团公司与“济钢”（被告抢注网络域名）
- 负面案例
 - 厦门大学诉上海厦大房地产公司

清华早读

四、姓名

- 姓名（包括笔名、艺名、译名等）



保护的是姓名
识别性所带来
的商业价值

姓名保护中的问题在于姓名本身是否具有唯一性？

王跃文诉王跃文案

- 湖南王跃文诉河北王跃文、北京中元瑞太国际文化传播有限公司、华龄出版社等著作权侵权、不正当竞争纠纷一案中，原告湖南王跃文系国家一级作家，以官场小说见长，其1999年创作的代表作《国画》被“中华读书网”评为十大经典反腐小说。
- 被告河北王跃文原名王立山，于2004年改名为王跃文。由华龄出版社出版、中元公司发行的长篇小说《国风》封面标注作者为“王跃文”，并介绍其为“河北遵化人氏”、“发表几百万文字”、“著名作家”。

乔丹诉乔丹案

美国篮球运动员乔丹向法院提出诉讼，要求中国乔丹体育公司撤销关于“QIAODAN”、“乔丹”、“乔丹王”在内的多个争议商标



- 乔丹公司提交了相关证据说明中国有4200多位乔丹。乔丹也被广泛应用于企业字号中，通过中国组织机构代码机构查询，中国企业字号里带乔丹的企业有上百家。

背景

- 乔丹体育股份有限公司成立于**1984**年，总部位于中国福建省晋江市，前身是“福建省晋江陈埭溪边日用品二厂”，于**2000**年正式更名为“乔丹体育”。
- **Michael Jordan**（中文名：迈克尔·乔丹）

北京高院认为

- 公民的姓名权、肖像权作为在先权利受《商标法》的保护。具体到本案，即便“**Michael Jordan**”中文翻译为“迈克尔·乔丹”，但争议商标中的“乔丹”并不惟一对应于“**Jordan**”，且“**Jordan**”为美国人的普通姓氏而不是姓名，故现有证据不足以证明“乔丹”确定性指向“**Michael Jordan**”和“迈克尔·乔丹”，故迈克尔·乔丹主张争议商标损害其姓名权的依据不足。

最高法院认为

- “乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉，我国相关公众通常以“乔丹”指代迈克尔·杰弗里·乔丹，并且“乔丹”已经与迈克尔·杰弗里·乔丹之间形成了稳定的对应关系。
- 但乔丹对于**QiaoDan**不享有权利

中国人的英文姓名是否可以主张权利？

WWW.CTMO.GOV.CN SBJ.SAIC.GOV.CN 帮助 数据更新时间：(2018年01月13日)

商标详情 商标流程 无效宣告请求裁定书商评字[2017]第0000136772号

 JACK MA

商品/服务 电池充电器; 电池箱; 电解装置; 电源材料(电线、电缆); 电站自动化装置; 工业用放射屏
幕; 蓄电池; 阳极电池; 阴极反腐蚀装置; 运载工具用蓄电池; [查看详细信息](#)

类似群 0912;0914;0915;0918;0922;

申请/注册号 13733662 申请日期 2013年12月16日 国际分类 9

申请人名称(中文) 马绵捷

申请人名称(英文)

申请人地址(中文) 广东省汕头市潮南区陈店镇流仙仙南中路120号

申请人地址(英文)

初审公告期号 1440 注册公告期号 1452 是否共有商标 否

初审公告日期 2015年01月20日 注册公告日期 2015年04月21日 商标类型 一般

专用权期限 2015年04月21日至2025年04月20日 商标形式

知产库

- 商评委认为：

- 申请人提交的证据能够证明申请人法定代表人的中文姓名“马云”与其英文名“JACK. MA”对应且在争议商标注册申请日之前，于电子商务、互联网领域享有较高知名度，为大众公众所熟知。
- 本案争议商标由外文“JACK. MA”构成，与申请人法定代表人马云先生的英文名“JACK MA”字母构成、呼叫相同。且被申请人未陈述其使用“JACK. MA”这一姓名作为商标注册的合理理由。

非直接使用知名商品名称？

- 电影《御魂师》翻拍手游《阴阳师》不正当竞争案



- 《御魂师》电影会造成消费者误认电影与涉案游戏之间存在关联关系。被告抗辩“御魂”属于公有领域的词汇，经当庭通过百度搜索“御魂师”，前五页中仅有极少部分链接与《阴阳师》游戏无关，在案证据亦可证明众多游戏玩家将“阴阳师”等同于“御魂师”，可见“御魂师”与《阴阳师》游戏已存在相对稳定的联系。

内容提要

- 概述
- 擅自使用商品类标识
- 擅自使用商号类标识
- 擅自使用互联网类的标识及其他

“（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页、**新媒体账号名称、应用程序名称或图标**等；”



对互联网行业的特别“关照”

域名

- 域名是互联网上用户**IP**地址的代号。
- 问题：
 - 抢注域名
 - 不同后缀：**cn, net, com, gov**
 - 中文域名：谷歌 **vs Google**
 - 中文拼音域名：**Guge vs Google**
- 是否会限制竞争？
 - 案例：都快公司诉王林阳案
 - 原告注册**19floor.com**
 - 被告注册**19floor.net**
 - 分析要点
 - 域名类似
 - 网站的栏目设置和页面布局类似
 - 原告具有一定的知名度

两者主营业务不同，所以不影响

新媒体账号

- 原告**A**公司与主播**B**签订《主播合作协议》，约定**B**根据**A**公司运营需求，通过快手、抖音、淘宝等平台以“杜某一”系列账号开展直播带货活动。后**B**及**B**公司注册了多个“杜某依”系列账号，并发布视频称“原杜某一相关账号异常”、“要求粉丝关注杜某依账号”等信息。**A**公司得知后大为不满，认为该行为侵犯其名称权及商誉，构成不正当竞争，遂诉至法院。
- 一审及二审法院均认定，**B**和**B**公司注册并使用“杜某依”账号昵称宣传销售商品的行为，侵害了**A**公司就“杜某一”账号享有的竞争性权益，应承担停止侵权、连带赔偿经济损失和维权合理费用等法律责任。

应用程序名称图标



不会造成误认



AI 智能办公文档产品



会造成误认，受反法保护



“（四）**其他**足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”

其他具有区分商品来源功能的客体也可能被混淆，但需要审慎地适用：

第一，对性质上属于标识，未在前三项明示列举的；

第二，该客体同样需要达到“有一定的影响”；

第三，其他法律予已保护的客体应鼓励通过其他法律制止混淆而不宜纳入本条的兜底规定。

如游戏人物、广告语等

广告语

- 广药集团诉加多宝

可能存在地方保护主义



“怕上火喝王老吉”广告语的权利归属于两原告，故被告加多宝公司使用“怕上火喝加多宝”广告语会使消费者认为生产“加多宝”产品的企业与生产“王老吉”产品的企业具有许可使用，不当增加了“加多宝”产品的竞争优势，从而损害两原告的合法权益。法院同时推断，加多宝公司使用的“怕上火，喝正宗凉茶；正宗凉茶，加多宝”、“怕上火，喝正宗凉茶”广告语构成不正当竞争。

关键词隐形使用？

- 一、海亮方与荣怀方均为浙江省诸暨市的教育服务提供商，存在直接竞争关系。海亮方拥有“海亮”“海亮教育”等注册商标，并通过长期经营积累了较高的市场知名度。
- 二、荣怀方在360搜索引擎的点睛平台后台设置了43个包含“海亮”“海亮教育”等字样的关键词，用于推广自身网站。当用户搜索“海亮”时，荣怀方的推广链接出现在搜索结果靠前位置，但链接标题和描述中未直接显示“海亮”字样，仅标注“广告”标记。
- 三、最高人民法院再审认为，荣怀方的“隐性使用”行为构成不正当竞争，改判荣怀方赔偿260万元，并责令其停止侵权行为。

混淆要件？

- 1、反不正当竞争法所规制的“不正当竞争行为”并不以“导致混淆、误认”为构成要件，而是制止有悖诚实信用原则、商业道德准则的行为。
- 2、将竞争对手的知名名称设置为关键词“隐性使用”的方式来推广自身的品牌，不应予以鼓励和提倡。
- 3、搜索引擎具有公益性，关键词“隐性使用”会干扰搜索服务的正常运行。
- 4、消费者的信息获取权不应以其它经营者的合法权益及公平竞争秩序为代价。

与反法规定是否相冲突？

侵权抗辩

- 正当使用：诚信有合理理由的使用



浙江食品有限公司



永康火腿厂
“真方宗”



杭州张小泉v上海张小泉

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>